

निषेधाज्ञा

श्यामकुमार भट्टराई

न्यायाधीश, उच्च अदालत पाटन

परिचय

निषेधाज्ञा कानून लको समन्यायिक विधिशास्त्रबाट विकास भएको अवधारणा हो। कानून लमा पनि यो रोमन लको prohibitory Interdict बाट विकास भएको हो। यो रिट होइन । यो रिटको प्रकृतिको निवेदनमा हुने आदेश हो। निषेधाज्ञा भनेको सामान्यतया मुद्दाहरूमा हुने बीच बीचको झन्झट रोक निमित्त र तत्कालीन संकटको समाधान गर्ने अन्तरिम व्यवस्थाको उपाय हो। निषेधाज्ञाको व्यवस्था समन्यायको सिद्धान्तबाट प्रादुर्भाव भएको र यसको रूप मुद्दाको स्वभाव अनुसार निषेधात्मक वा निर्देशात्मक दुवै हुन्छ । कुनै कार्य गर्नबाट निषेध गर्न वा कुनै कार्य गर्न दिनु पर्ने अदालतको आदेशबाट कुनै व्यक्तिको कानूनी अधिकारको विषयमा अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म यथास्थितिमा कायम राख्ने हुन्छ । यसबाट कुनै व्यक्तिको हक सृजना गर्ने वा समाप्त गरिने कार्य हुँदैन । यसले विवादित कार्यबाट हुने आशंकित आघातलाई रोक्ने, बढी नोक्सानी हुन नदिने वा हालको स्थितिलाई कायम राख्ने कार्य मात्र गर्छ ।¹ निषेधाज्ञाको आदेशले न त हक बेहक गराउँछ न त यसले कसैको हकको सृजना गर्छ, यो त यथास्थिति कायम राख्ने Preventive उपचारको बाटो हो ।² निषेधाज्ञा जारी हुनका लागि जुन सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने भनिएको हो सो सम्पत्तिमा निवेदकको पूर्ण हक (Absolute Right) अथवा विवादरहित हक (Undisputed Right) हुनपर्ने³ हुन्छ।

यो मुख्यरूपमा न्यायिक स्वविवेकको विषय हो तर त्यस्तो स्वविवेक समन्यायिक दृष्टिकोण (equitable considerations) मा आधारित हुनु पर्दछ। प्रतिबाधक उपायको दृष्टिबाट हेर्दा निषेधाज्ञा प्रतिषेधसँग दाँज्न सकिन्छ। तर सामान्य र उपयुक्त अवस्थामा प्रतिषेधको उपाय लाग्ने भए प्रतिषेधको सट्टा निषेधाज्ञा जारी हुन सक्दैन । निषेधाज्ञाको दुई रूप हुन सक्छ। निर्देशनात्मक र निषेधात्मक। निर्देशनात्मक निषेधाज्ञाबाट कसैलाई कुनै कुरा गर्नु भनी गर्न लगाउने र निषेधात्मक निषेधाज्ञाबाट कुनै कुरा गर्न वा गरिरहनबाट मनाही गर्ने आदेश जारी गरिन्छ। निषेधाज्ञा एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसले कुनै कानूनी गल्तीलाई रोकेर कानूनी हकको संरक्षण (as a process for preventing wrong and preserving the rights) गर्दछ। त्यसैले निषेधाज्ञालाई रिटको कोटीमा राखेर असाधारण उपचारको प्रबन्धको रूपमा लिने गरिन्छ⁴ तथापि निषेधाज्ञाको आदेश अदालतले साधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत गर्ने गर्दछन्।

नोट: यो लेख प्राज्ञिक छलफलका लागि तयार गरिएको हो। यहाँ उल्लिखित लेखकका व्यक्तिगत धारणाले लेखकको पदीय जिम्मेवारी र कार्यरत निकायको प्रतिनिधित्व गर्दैन।

¹ कृष्णबहादुर चिपालु विरुद्ध हिमालयन टि सेन्टरका साझेदार रामकुमार राठी, ने.का.प. २०५२ अङ्क ९ निर्णय नं. ६०७२

² कृष्णबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध तुल्सीभक्त श्रेष्ठ, ने.का.प. २०४८ अङ्क २, ३, ४ निर्णय नं. ४२७४

³ देवेन्द्र साहसमेत विरुद्ध जगदेव साह हलुवाई, नेकाप २०७४ अंक ८ नि नं ९८५७

⁴ कुनै पनि नागरिकलाई अन्याय परेको विषयमा वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटो नरहेको वा भए तापनि प्रभावकारी नभएको अवस्थामा मात्र संविधानले प्रदान गरेको असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी अदालतले रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्छ । अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा मातहतका अदालतमा सामान्य क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कानूनबमोजिम दायर भई विचाराधीन रहेका मुद्दालाई असर पार्ने कार्य गर्न मिल्दैन । प्रत्येक अदालत आफूसमक्ष विचाराधीन मुद्दामा इन्साफ गर्न सक्षम र स्वतन्त्र छ भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तको आधारमा कुनै पनि कानूनी प्रणाली चलेको हुन्छ । मातहतको अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा माथिल्लो तहको अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने विधि, प्रक्रिया र न्यायिक प्रणाली अन्यौलग्रस्त हुन पुग्दछ । पिताम्बर के.सी. विरुद्ध बुटवल फाइनेन्स हाल सिनर्जी फाइनेन्स लि. नेकाप २०७६ अंक ४ नि नं १०२३९

दावी स्थापित गर्ने दायित्व निवेदकमा

निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्ने निवेदकले आफ्नो दावी स्थापित गर्ने दायित्व शंकारहित तवरले पुष्टि गर्नु पर्दछ। खासगरी निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकको हनन् हुने आशंका रहेको वा हनन् गर्ने कार्य भैरहेको अवस्था प्रथमदृष्टिमा नै विश्वासिलो रुपमा देखाउन सक्नु पर्दछ भने त्यसबाट परिपूरण नै हुन नसक्ने गरी निवेदकलाई क्षति हुने अवस्था रहेको देखाउनु पर्दछ। यो समन्यायिक दृष्टिले हेरिने अवधारणा भएकोले सुविधा र सन्तुलन पनि निवेदकको पक्षमा हुनु पर्दछ। त्यसैले निषेधाज्ञाको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा उल्लिखित आधारहरु नै ग्रहण गरिन्छ। निषेधाज्ञाको उपचार खोजी गर्ने निवेदक स्वयम् सफा हात लिएर अदालत आएको हुनु पर्दछ र झुठो दावी लिएर आउने निवेदकलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन अर्थात् "one who comes to the court, must come with clean hands. More often than not, process of court is being abused."⁵ भन्ने मान्यता निषेधाज्ञाको निवेदनमा पनि उत्तिकै बाध्यकारी रुपमा आकर्षित हुन्छ। आफू इमानमा नबसी कानूनी उपचार खोज्ने निवेदक (dishonest litigants) लाई निषेधाज्ञाको रोहबाट अदालतले सहयोग गर्ने सक्दैन भन्ने मानिन्छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले भनेको छ *a fraud is an act of deliberate deception with the design of securing something by taking unfair advantage of another. It is a deception in order to gain by another's loss. It is a cheating intended to get an advantage. Non-disclosure of the facts amounts to "playing fraud on the Court"*⁶

निषेधाज्ञा र रिटमा भिन्नता

निषेधाज्ञाको आदेश र रिटमा भिन्नता छ । तथापि यी दुवै निवेदनको सुनुवाई प्रक्रिया लगभग समान भएको र निषेधाज्ञाको निवेदन पनि हक अधिकार प्रचलनका लागि अदालतलाई प्रदान गरेको विशेषाधिकार भएकोले धेरै विषयमा समानता देखिन्छ। तर अवधारणागत रुपमा र अभ्यासका दृष्टिले पनि निषेधाज्ञा र रिटमा सारभूत भिन्नता छ। उक्त भिन्नतालाई देहायको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:

निषेधाज्ञा	भिन्नताका आधार	रिटहरु
निर्विवाद कानूनी हकको संरक्षण लागि जारी गरिन्छ।	जारी गरिने आधार	संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको प्रचलनका लागि जारी गरिन्छ।
जिल्ला अदालत र उच्च अदालत	जारी गर्ने अदालत	सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालत
निषेधाज्ञाको आदेश उपर एक तह पुनरावेदन लाग्दछ।	पुनरावेदन	रिटमा पुनरावेदन लाग्दैन। उच्च अदालतले रिटमा गरेको आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्‍याइ पाउने निवेदन लाग्दछ।
निषेधाज्ञामा आवश्यकता अनुसार प्रमाण बुझ्ने गरिन्छ। नापनक्सा गर्ने वा सर्जिमिन गर्ने	प्रमाण मुकरर	सामान्यतया रिटमा प्रमाण बुझ्ने गरिँदैन। तथ्यको निरोपण गरिँदैन।

⁵ Mr. Jagannath case, <https://ijtr.nic.in/articles/art25.pdf>

⁶ Mr. Jagannath case, <https://ijtr.nic.in/articles/art25.pdf>

जस्ता कार्य गर्न सकिन्छ।		
निषेधाज्ञामा कानूनी हक अधिकार भएका व्यक्ति वा संस्थासमेतले उपचार खोजी गर्न सक्छन्।	पक्ष विपक्ष	सामान्यतया हक अधिकार हनन् भएको अवस्थामा व्यक्तिले सरकारी वा सार्वजनिक निकाय उपर रिट दायर गर्ने गरिन्छ।
निषेधाज्ञाको निवेदन व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध पनि दायर गरिन्छ।	व्यक्तिका विरुद्धको उपचार	बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट बाहेक अरु रिटहरु व्यक्ति वा निजी संस्था वा कम्पनीका विरुद्ध दायर गर्न सकिँदैन।

कस्तो अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी गरिन्छ<

कानूनले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकारको संरक्षणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिन्छ। निषेधाज्ञाको बारेमा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ: निषेधाज्ञा जारी हुनका लागि जुन सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने भनिएको हो सो सम्पत्तिमा निवेदकको पूर्ण हक -Absolute Right_ अथवा विवादरहित हक -Undisputed Right_ हुनुपर्ने। सम्पत्तिको आफ्नो हक निहीत रहेको तथ्यपूर्ण एवं सारभूत प्रमाण देखाउन नसकेको अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने हुन्छ। ऐनद्वारा प्रत्याभूत हकमा आघात पर्ने आशंका व्यक्त गर्नेले सर्वप्रथम आफ्नो हकलाई आधारभूत र सारभूत रूपमा -Substantially_ स्थापित गर्न सक्नुपर्ने। निषेधाज्ञाको रोहमा कुनै सम्पत्तिमा हक स्वामित्व कायम गर्न वा गराउन नसकिने हुन्छ।⁷ साधारण कानूनी प्रक्रियाबाट नै उपचार पाउने व्यवस्था छ भने निषेधाज्ञाको उपचार लिनु पर्ने र दिनु पर्ने आवश्यक हुँदैन।⁸ निषेधाज्ञा मुद्दाबाट हक स्थापना नहुनेले स्थापित हकमा पर्न सक्ने अवरोध सम्म निषेध गर्न सक्ने हुन्छ।⁹ अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी निषेधाज्ञाको निवेदन जारी गर्न मिल्दैन।¹⁰

House of Lords ले एउटा प्रशिद्ध मुद्दा American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd. मा निषेधाज्ञाको बारेमा शूत्रबद्ध व्याख्या गरेको पाइन्छ। लर्ड डिप्लकले गरेको सो व्याख्याको सार देहाय बमोजिम रहेको छ:¹¹

(1) The plaintiff must first satisfy the court that there is a serious issue to decide and that if the defendants were not restrained and the plaintiff won the action, damages at common law would be inadequate compensation for the plaintiff's loss.

(2) The court, once satisfied with these matters will then consider whether the balance of convenience lies in favour of granting an injunction or not, that is, whether justice would be best served by an order of injunction.

⁷ लाहान नगरपालिका विरुद्ध लक्ष्मी महतो, नेकाप २०६८ अंक ११ नि नं ८७१२

⁸ चन्द्रावती देवी कसौधन वि मालपोत कार्यालय, रुपन्देही, ने.का.प. २०५३ अंक ३ निर्णय नं. ६१५७

⁹ गणेशबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध केशवप्रसाद श्रेष्ठसमेत, ने.का.प. २०५२ अङ्क १२ निर्णय नं. ६११९

¹⁰ मनोहर शाह विरुद्ध यदुनन्दन शाह, ने.का.प. २०५२ अङ्क ११ निर्णय नं. ६१०७

¹¹ <https://www.scconline.com/blog/post/2022/06/28/extent-existence-and-expiry-of-interim-orders-a-judicial-enigma-part-i/>

(3) The court does not and cannot judge the merits of the parties' respective cases and that any decision of justice will be taken in a state of uncertainty about the parties' rights.

भारतको सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयलाई यसप्रकार सूचीकरण गरिदिएको छः¹²

- (i) Extent of damages being an adequate remedy.
- (ii) Protect the plaintiff's interest for violation of his rights though, however, having regard to the injury that may be suffered by the defendants by reason thereof.
- (iii) The court while dealing with the matter ought not to ignore the factum of the strength of one party's case is stronger than the other's.
- (iv) No fixed rules or notions ought to be had in the matter of grant of the injunction but on the facts and circumstances of each case — the relief being kept flexible.
- (v) The issue is to be looked at from the point of view as to whether on the refusal of the injunction the plaintiff would suffer irreparable loss and injury keeping in view the strength of the parties' case.
- (vi) Balance of convenience or inconvenience ought to be considered as an important requirement even if there is a serious question or prima facie case in support of the grant.
- (vii) Whether the grant or refusal of the injunction will adversely affect the interest of the general public which can or cannot be compensated otherwise.

अवधिका हिसावले निषेधाज्ञा

अदालतबाट जारी गरिने अवधिका हिसावले निषेधाज्ञाको आदेशलाई अस्थायी, आवधिक र स्थायी प्रकृतिको निषेधाज्ञा भनी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। कुनै निश्चित शर्त पूरा नहुन्जेलका लागि जारी गरिने निषेधाज्ञाको आदेशलाई अस्थायी प्रकृतिको आदेश भनिन्छ। कुनै निश्चित समयावधिसम्मका लागि जारी गरिने आदेशलाई आवधिक निषेधाज्ञा भनिन्छ। अनन्त कालसम्मका लागि जारी गरिने निषेधाज्ञाको आदेशलाई स्थायी प्रकृतिको निषेधाज्ञाको आदेश भनिन्छ।

परमादेश, प्रतिषेध र निषेधाज्ञा

परमादेश र प्रतिषेध दुवैको केही रूप निषेधाज्ञामा झल्किन्छ तापनि परमादेश र प्रतिषेध जस्तो संवैधानिक उपचारका असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्रका पूर्जी आदेशहरू भन्दा कुनै अवस्थामा निषेधाज्ञा छिटो र बलियो उपाय हुन जान्छ।¹³

¹² <https://www.scconline.com/blog/post/2022/06/28/extent-existence-and-expiry-of-interim-orders-a-judicial-enigma-part-i/>

¹³ निषेधाज्ञाको उद्देश्य—निषेधाज्ञा र प्रतिषेधमा समानता—तापनि सामान्यतः प्रतिषेधको सट्टा निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने। निषेधाज्ञाको दुई रूप : (१) वाध्यात्मक (२) निषेधात्मक। निषेधाज्ञा भनेको मुद्दाहरूमा हुने बीच बीचको झन्झट रोक्न निमित्त र तत्कालिन संकटको

शुद्ध कारबाहीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पक्षहरूलाई यथास्थितिमा राखी निषेधाज्ञाबाट धेरै जस्तो अवस्थामा छिटो काम हुने मात्र होइन कि तत्कालीक कठिनाई समाधान गर्ने अन्तरिम व्यवस्थाको उपाय पनि हो ।¹⁴ यस किसिम निषेधाज्ञा मुद्दाको सिलसिलामा गरिने कारबाही सम्बन्धी एउटा अन्तरकालीन व्यवस्थाको उपाय हो भन्ने स्पष्ट छ । नेपालको वर्तमान संविधानले निषेधाज्ञाको निवेदन सुनुवाइ गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको बारेमा भनेको छ ः मुलतः अदालतले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्दा हुन गइरहेको वा भइरहेको काम कारोबारबाट कुनै पनि व्यक्तिको कानूनी हकमा आघात पर्न जाने स्थितिको आशंकाको विद्यमानतालाई नै हेर्ने गरिन्छ र त्यस्तो आशंका तथ्यपरक एवं प्रमाणपरक ढंगले पुष्टि भएको पनि हुनुपर्छ । निषेधाज्ञाको रिटबाट उपचार खोज्ने पक्षले आफूलाई मर्का परेको कुराको आशंकाको विद्यमानता रहेको कुरामा अदालतलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । यसैगरी, सहज र पहुँचयोग्य अन्य उपचार र मार्ग भएसम्म यो रिट जारी गर्न पनि मिल्दैन । यद्यपि पुनरावेदकले जिकिर लिए झैं निषेधाज्ञाको मुद्दामा नक्सा सर्जिमनलगायतको प्रमाण बुझ्न नसकिने होइन तर त्यस्तो प्रमाण बुझी प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने कुरामा अदालत विश्वस्त हुनुपर्ने ।¹⁵

निषेधाज्ञामा पनि अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ, जसका आधारहरू यस प्रकार छन् ः¹⁶

- १) अधिकारमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने आशङ्कित स्थिति विद्यमान छ,
- २) अन्तरिम आदेशको राहत नदिएमा अपूरणीय क्षति हुने प्रबल संभावना छ,
- ३) अन्तरिम आदेश नदिएमा अदालतमा दायर भएको मुद्दालाई गम्भीर असर पार्दछ,
- ४) निर्णय पछि पक्षको कानूनी अधिकार प्रचलन गराउन नसक्ने अवस्था आइपर्छ,
- ५) अचल सम्पतिको स्वरूप नै परिवर्तन हुने वा हक हस्तान्तरण हुन सक्ने वा नास हुने अवस्था छ,
- ६) विवादित विषय यथास्थितिमा राख्नु पर्ने अवस्था अदालतलाई मुनासिव लाग्छ,
- ७) अन्तरिम आदेश जारी गर्दा परिणाम सकारात्मक हुने स्थिति देखिनु पर्छ, र
- ८) उपरोक्त कुराहरू निवेदन मागबाटै प्रथम दृष्टिमा (Prima Facie) देखिनुपर्छ ।

समाधान गर्ने अन्तरिम व्यवस्थाको उपायको हो । प्रतिबन्धक उपायको दृष्टिबाट हेर्दा निषेधाज्ञा प्रतिषेधसँग दाँज्न सकिन्छ । तर सामान्य र उपयुक्त अवस्थामा प्रतिषेधको उपाय लाग्ने भए प्रतिषेधको सट्टा निषेधाज्ञा जारी हुन सक्दैन । निषेधाज्ञाको दुई रूप हुन सक्छ—वाध्यात्मक र निषेधात्मक । ‘वाध्यात्मक निषेधाज्ञाबाट कसैलाई कुनै कुरा गर्नु भनी गर्न लगाउने र निषेधात्मक निषेधाज्ञाबाट कुनै कुरा गर्न वा गरी रहनबाट मनाही गर्ने । यसरी परमादेश र प्रतिषेध दुवैको केही रूप निषेधाज्ञामा झल्किन्छ तापनि परमादेश र प्रतिषेध जस्तो संवैधानिक उपचारका असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्रका पूर्वी आदेशहरू भन्दा कुनै अवस्थामा निषेधाज्ञा छिटो र बलियो उपाय हुन जान्छ । शुद्ध कार्यवाहीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पक्षहरूलाई यथास्थितिमा राखी निषेधाज्ञाबाट धेरैजसो अवस्थामा छिटो काम हुने मात्र होइन कि तत्कालिन कठिनाई समाधान गर्ने अन्तरिम व्यवस्थाको उपाय पनि हो । यस किसिम निषेधाज्ञा मुद्दाको सिलसिलामा गरिने कार्यवाहीसम्बन्धी एउटा अन्तर्कालिन व्यवस्थाको उपाय हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । जनकसिंह सहगल विरुद्ध द्वारिकाप्रसाद आर्य ने.का.प. २०१९ अंक १० निर्णय नं. १७४

¹⁴ निषेधाज्ञा जारी हुनका लागि जुन सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने भनिएको हो सो सम्पत्तिमा निवेदकको पूर्ण हक (Absolute Right) अथवा विवादरहित हक (Undisputed Right) हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । देवेन्द्र साह समेत वि. जगदेव साह हलुवाई, नेकाप २०७४ अंक ८ नि.नं. ९८५७ । निषेधाज्ञाको बारेमा सूर्यभक्त साँगाछें समेत वि. विजय बहादुर राजभण्डारीसमेत, नेकाप २०५५ अंक ४ नि.नं. ६५३४ मा समेत सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ ।

¹⁵ गोमा कुमारी पण्डित वि. मनतोरियादेवी, नेकाप २०७४ अंक २ नि.नं. ९७६३

¹⁶ केशवराज पाण्डे, प्रशासकीय कानून, दोस्रो संस्करण, पृष्ठ २९६

अन्तरिम आदेश र अन्तरकालीन आदेशका बीचमा अवधारणागत भिन्नता छ। अन्तरिम आदेश रिट वा निषेधाज्ञाको रोहमा निवेदनमा उठाएको विषयमा माथि उल्लिखित आधारमा जारी गरिन्छ भन् अन्तरकालीन आदेश मुद्दाको कारवाही प्रक्रियामा जारी गरिन्छ।¹⁷

निषेधाज्ञाका सम्बन्धमा फुलकोर्टको निर्देशन

नागरिक अधिकार ऐन २०१२ ले निषेधाज्ञाको अधिकार प्रदान गरेपछि सो अधिकारको प्रयोगमा एकरूपता कायम गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले नियम सरहको निर्देशन जारी गरेको थियो । फुलकोर्टबाट जारी भएको नियम यसप्रकार छ ०:

- १) निषेधाज्ञा कुनै प्रस्तुत मुद्दा मामिलामा जारी गर्ने, नगर्ने विषयमा अवस्था हेरी अपिल सुन्ने अदालतले तजबिज गर्नुपर्छ, यो विषय उक्त अदालतको तजबिजको हो, सो जारी गरी माग्ने कुनै व्यक्ति वा पक्षको हक होइन ।
- २) निषेधाज्ञा कुनै कार्य गर्न निषेध वा मनाही गर्ने (Prohibitory) मात्र नभई सो जारी भएका निषेधाज्ञा कार्यान्वित गर्न यसो गर्नु भनी कर लगाउने पनि हुन सक्तछ ।
- ३) जुन मुद्दा मामिलामा अपिल अदालतका चित्तमा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिए न्याय पर्छ भन्ने लागेमा त्यस्तो काममा निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने छैन ।
- ४) यस्तो अन्तरकालीन निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने उजुर नालिस पर्दा साथ अपिल अदालतले उजुर लेखेको विषयमा उजुरवालाको देखादेखी (Prima Facie) हक दावी लाग्ने नलाग्ने के हो, विचार गरी हक दावी पुग्ने देखेमा मात्र निषेधाज्ञा जारी गर्नुहुन्छ त्यस्तो गर्नलाई अपिल अदालतले हक दावी प्रष्ट सबुद, प्रमाण दाखिल गर्न उजुरवालालाई कर लगाउन पनि सक्तछ ।
- ५) यस्तो निषेधाज्ञा जारी भएकाले विपक्षी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई मर्का पर्न गएमा त्यस्ता व्यक्तिले प्रचलित कानुनको रीत पुऱ्याई निषेधाज्ञा जारी गराई माग्ने पक्ष उपर नालिस गर्नु हुन्छ र त्यस्तो नालिस उजुर पर्न आएमा सुरु नालिस हेर्ने अदालतले पनि लिई प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्छ ।
- ६) उक्त निषेधाज्ञा जारी हुँदा वा सोभन्दा अगावै प्रस्तुत मुद्दा मामिलामा अवस्था हेरी विपक्षलाई बुझ्न न्यायोचित लागेमा अधिकृत अदालतले विपक्षलाई म्याद समन तामेल गरी बुझ्न हुन्छ सो नभई अवस्था विचार गर्दा तुरुन्तै अन्तरकालीन निषेधाज्ञा जारी गर्न आवश्यक आएमा एकतर्फी (ex parte) सुनुवाइबाट जारी गर्न पनि हुन्छ ।

¹⁷ अन्तरकालीन आदेश कुनै हक बेहकको निर्णय विचाराधीन रहेको स्थितिमा यथास्थितिमा नराखेमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएपछि पक्षको कानुनी अधिकार प्रचलन गर्न नसकिने अवस्था आई पर्ने वा अचल सम्पत्तिको स्वरूप नै परिवर्तन हुने वा हक हस्तान्तरण भैसके वा नास हुने स्थितिबाट रोक्नको लागि अदालतको विवेकमा अत्यावश्यक देखिएमा जारी गरिन्छ । यस्तो अन्तरकालीन आदेशबाट कुनै पक्षको हक सृजना वा समाप्त गरिदैन न त कुनै मुद्दाको अन्तिम निर्णयबाट हुने परिणाम नै अन्तरकालीन आदेशबाट प्राप्त हुने । कृष्णबहादुर चिपालु बिरुद्ध रामकुमार राठी, ने.का.प. २०५२ अङ्क ९ निर्णय नं. ६०७३

७) निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भनि निवेदनपत्र दिने निवेदकले अर्काले हक दावी आघात गर्न खोज्दा चित्त बुझाइरहेको वा अकारणवस ढिलासुस्ती गरी निवेदन वा उजुर गरेको वा हकदावीको विषयमा आफ्नोतर्फबाट कानुनले गर्नुपर्ने वा गर्न नहुने गरिसकेको देखिए मात्र निजको उजुरमा अदालतको विचार गर्नुपर्छ ।

८) यस्तो निषेधाज्ञा एक पटक जारी भएपछि मुद्दामामिलाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म वा अदालतले तोकेका मितिसम्म वा अर्काे आदेश जारी नगरेसम्म लागू रहनेछ ।

९) निषेधाज्ञा जारी भएका विषयमा सो आज्ञा नमान्ने उल्लङ्घन गर्ने पक्ष वा व्यक्तिलाई अदालतको अपहेलना वा बेइज्जती गरेबापत प्रचलित कानुनले तोकेको सजाय हुनेछ ।

१०) निषेधाज्ञा जारी गर्दा अदालतले मुनासिव किसिमको शर्त बन्देज (Condition) लगाई जारी गर्न पनि हुन्छ ।

११) एक पटक जारी गरेको निषेधाज्ञालाई अदालतले केही समयका लागि त्यस्ता गर्न उचित लागेमा स्थगित गर्न पनि हुन्छ ।

१२) निषेधाज्ञा जारी गर्न वा परिरहेको मुद्दै छिनी दिन जुन चाँडो हुन्छ सो गरी दिनुपर्छ ।

१३) निषेधाज्ञा 'नागरिक अधिकार ऐन, २०१२' ले कुनै नागरिकलाई दिएका अधिकार सुरक्षित गर्नलाई बाहेक अरु काममा जारी गर्न हुँदैन ।

संवैधानिक पहिचान

निषेधाज्ञालाई नागरिक अधिकारसँग जोडेर मात्र हेर्ने गरिएको थियो। यसलाई कानूनी अधिकारको रूपमा मात्र लिने गरिन्थ्यो। नेपालको वर्तमान संविधानले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने व्यवस्था गरी यो आदेशको संवैधानिक पहिचान प्रदान गरेको छ।¹⁸

कानूनी व्यवस्था

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद तीनमा रहेको नागरिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा २६ को उपदफा (३) मा कसैले यस परिच्छेद विपरीत कुनै काम गरेमा वा गर्न लागेको पर्याप्त आशंका भएमा त्यस्तो काम कारवाहीबाट मर्का पर्न जाने व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रचलनका लागि प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा (५) मा उपदफा (३) बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा प्रत्यर्थीले निजको अधिकारमा केही क्षति पुर्याएको वा क्षति पुर्याउन लागेको देखिएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो प्रत्यर्थीको नाममा उजुर गर्ने व्यक्तिको अधिकार उपर क्षति पुग्ने किसिमको काम नगर्न नगराउन र केही काम गरिसकेको भए बाँकी काम नगर्न वा कुनै

¹⁸ नेपालको संविधानको धारा १५१ मा रहेको जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्रमा जिल्ला अदालतलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञालगायतका कानून बमोजिमका निवेदनहरु हेर्ने अधिकार हुने व्यवस्था छ।

काम गर्न लगाउन आदेश जारी गर्न सकेछ भन्ने व्यवस्था छ। सोही परिच्छेदको दफा २७ मा प्रत्यर्थीले उजुरकर्तालाई बदनियतपूर्वक क्षति पुग्ने कुनै काम गरेको ठहरिएमा सम्बन्धित अदालतले अवस्था हेरी प्रत्यर्थीबाट उजुरकर्तालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिने र सरकारी वा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीले सो अनुसारको काम गरेको ठहरिएमा क्षतिपूर्तिको रकम त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारी आफैले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी दफा २८ मा कसैले कसैलाई दुख दिने वा हानि नोक्सानी पुर्याउने नियतले झुट्टा उजुरी दिएको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले त्यसरी झुट्टा उजुरी दिने उजुरीकर्ताबाट प्रत्यर्थीलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिनेछ भन्ने व्यवस्था छ। सो परिच्छेदको दफा २९ मा हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार मर्का पर्ने व्यक्तिले गिरफ्तार वा थुनिएको हकमा जहिलेसुकै र अन्य अवस्थामा त्यस्तो काम कारवाही भएको मितिले छ महिनाभित्र नालिस गर्न सकेछ।

नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ मा सो ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरु दावी गर्ने अरु उपाय अन्तरगत गरिएका व्यवस्था यसप्रकार रहेका थिए

(१) यस ऐनद्वारा प्रदत्त कुनै अधिकारमा कसैले आघात गर्ने शंका लागेमा उच्च अदालतमा उजुरी दिने सकेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरीमा सम्बन्धित अदालतले जाँचबुझ गरी प्रतिवादीलाई सो नगर्नु भनी निषेधाज्ञा दिने सकेछ।

(३) कसैले कसैको ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारमा आघात गरेमा अवस्था हेरी सम्बन्धित अदालतले ठहर गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५८, १५९ र १६० मा अन्तरिम आदेश र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्था गरिएको छ।

साविक नागरिक ऐनको व्यवस्थाको तुलनामा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले गरेको कानूनी व्यवस्था फराकिलो रहेको छ। साविकमा आशंकाको अवस्थामा मात्र निषेधाज्ञा जारी गरिने कानूनी व्यवस्था भएकोमा वर्तमान कानूनी व्यवस्थामा कुनै काम गरेमा वा गर्न लागेमा भन्ने शब्दावली राखी विस्तार गरिएको छ भने साविकमा कुनै काममा रोक लगाउन मात्र निषेधाज्ञा जारी गर्न सकिनेमा वर्तमान कानूनले कुनै काम गर्न लगाउन सके गरी सकारात्मक प्रबन्ध पनि गरेको छ। त्यसैगरी साविकमा निवेदकलाई क्षतिपूर्ति भराउने सम्मको व्यवस्था रहेकोमा वर्तमान कानूनमा निवेदकले झुट्टा उजुरी दिएको अवस्था देखिए प्रत्यर्थीलाई समेत क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिन सके व्यवस्था गरिएको छ। यसका अलावा निषेधाज्ञाको निवेदनका लागि आवश्यक कार्यविधिगत प्रबन्ध समेत मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ ले गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोण

निषेधाज्ञाको निवेदनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा गरेको व्याख्याको सारसंक्षेपलाई बुँदागत रुपमा यसप्रकार उल्लेख गरिएको छः

क. करार समाप्त भैसकेपछि करारअनुसार राखिएका सामानहरूको स्वामित्व सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा निषेधाज्ञाको निवेदनबाट हक स्वामित्वको निर्णय हुन नसक्ने । करारबमोजिम आफूले राखेका सामानहरू करार समाप्त भएपछि उठाई लान नदिएमा वा नोक्सानी गरेको भएमा त्यस्तो साम्प्रतिक अधिकारसम्बन्धी छुट्टै विवादको विषय बन्न जाने र त्यसमा सामान्य कानूनी उपचारको व्यवस्था आकर्षित हुने ।¹⁹

ख. निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुँदा कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्नलाई रोक लगाएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा कानूनबमोजिम आफ्नो अख्तियारीभित्रको क्षेत्रमा कानूनको प्रक्रियाबमोजिम कारवाही गर्नलाई यस्तो आदेशले नरोक्ने ।²⁰

ग. ऐनद्वारा प्रत्याभूत हकमा आघात पर्ने आशंका व्यक्त गर्नेले सर्वप्रथम आफ्नो हकलाई आधारभूत र सारभूत रुपमा (Substantially) स्थापित गर्न सक्नुपर्ने । निषेधाज्ञाको रोहमा कुनै सम्पत्तिमा हक स्वामित्व कायम गर्न वा गराउन नसकिने हुन्छ । अन्यथा भएकोमा बाहेक सर्वे नापीले कुनै जग्गाको चारकिल्ला क्षेत्रफल, स्वामित्व, मोही अवस्थितिलगायतको स्थितिलाई कानूनी तवरबाट निश्चितता प्रदान गर्दछ । त्यसमा चित्त नबुझे कानूनले तोकेको म्याद र प्रक्रियाबमोजिम तोकिएको अधिकारीबाट संशोधन गराउनु पर्ने, दर्ता नभएकोमा दर्ता गराई लिनुपर्ने ।²¹

घ. कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले कानून छाडी नागरिक अधिकार माथि धावा बोल्ने कार्य गरेको छ वा गर्दछ भने त्यसको उत्तरदायित्व उसैले बहन गर्नुपर्ने । सार्वजनिक अधिकारीको गैरकानूनी काम कारवाहीबाट नागरिकको हकाधिकार माथि आघात परेको अवस्थामा निज उपर दावी लिई उचित क्षतिपूर्ति भराई लिन सकिने नै हुँदा मर्का पर्ने व्यक्तिले सोही उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने ।²²

ङ. धितो राखी जुन कार्यको लागि कर्जा लिएको हो, सो कार्य गर्न सकिन भनी जिकिर लिँदा ऋण लिएको साँवा व्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था कुनै कानूनले गरेको नदेखिदा ऋण मिन्हा पाउँ भनी दिएको निवेदनमा कुनै कार्यवाही भएको छैन भनी साँवा व्याज नतिरी बस्नु न्यायसंगत नदेखिने । धितो रहेको

¹⁹ इरकन इन्टरनेशनल लि. को तर्फबाट ऐ. का अधिकारप्राप्त कार्यालय प्रमुख परियोजना प्रबन्धक एस. के. सावंत विरुद्ध रावनीदेवी महतोसमेत ने. का. प. २०६९, अङ्क ११ निर्णय नं. ८९१८

²⁰ धनई साह कानुन विरुद्ध जितेन्द्रप्रसाद साह कानुन नेकाप २०७७ अंक १२ नि नं १०६१५

²¹ लाहान नगरपालिका वि. लक्ष्मी महतो, नेकाप २०६८ अंक ११ नि नं ८७२१

²² कलावती ऐरसमेत विरुद्ध सुदुरपश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. १ महेन्द्रनगर समेत, ने. का. प. २०६५ अङ्क ९ निर्णय नं. ८०१०

अचल सम्पत्तिबाट लिलाम गरी बैंकले आफ्नो साँवा ब्याज रकम असुल गर्न सक्ने हुँदा निवेदन दावी खारेज हुने ठहर्याई गरेको शुरु आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने।²³

च. एकासंगोलमा रहेको अवस्थामा बाबुले लिएको ऋण कर्जा असुल गर्न वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ मा भएको कानूनी प्रावधानका आधारबाट बैंकले अन्य संगोलका अंशियारको सम्पत्तिबाट समेत लिलाम गरी कर्जा असुल उपर गर्न नसक्ने भन्न मिल्दैन। कानून बमोजिम बैंकले कर्जा असुल गर्ने सम्बन्धी कारवाहीलाई रोक लगाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने देखिँदैन।²⁴

छ. बैंकबाट लिएको ऋण साँवा र ब्याज सेमत पुनरावेदकले नबुझाएको अवस्थामा धितो रहेको सम्पत्ती लिलाम गरी ऋण असुल गर्ने प्रकृया अनुसार लिलामी सुचना प्रकाशित गरेको बिपक्ष बैंकको कार्यबाट निवेदकको हकाधिकारमा आघात पर्ने अवस्था बिद्वमान नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।²⁵

ज. कानून प्रदत्त अधिकार बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्यलाई अवरुद्ध हुने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने।²⁶

ज. ऋण लिए पछि तोकिएको समय भित्र सो ऋणको साँवा ब्याज तिर्नु बुझाउनु ऋणीको प्रमुख दायित्व हुने। ऋण दिने संस्थालाई पनि सर्तमा तोकिएको समयमा ऋण असुल हुन नसकेमा कानून बमोजिम गरी लिन पाउने कानूनले अधिकार प्रदान गर्ने। आफ्नो अधिकार भित्र रही ऋण असुल गर्न लिलामको सूचना प्रकाशित गरिएबाट पुनरावेदकको सम्पत्ति अनाधिकृत रुपमा कब्जा गर्न लागिएको भन्न नमिल्ने।²⁷

झ. निषेधाज्ञा मूलतः कार्य हुने आशंकाको स्थितिमा निर्विवाद हक भोग देखिएकोमा मात्र जारी गर्ने हो। विवादीत जग्गामा हक बेहकको प्रश्न उठी दुई पक्ष बीच अदालतमा झगडा परिरहेको स्थितिमा अदालतबाट अन्तिम टुंगो नलागेसम्म त्यस्तो विवादको जग्गामा प्रतिवादीबाट जुन कार्य गर्न लागेको आशंकाको स्थिति छ सो कार्य हुन दिने हो र परिरहेको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न

²³ बसिर अहमद राइन विरुद्ध कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय, गुलरिया, वर्दीया समेत ने.का.प. २०६० अङ्क ९.१० निर्णय नं. ७२८४

²⁴ नारदप्रसाद थारु समेत विरुद्ध महारानी थरुनी समेतने.का.प. २०६० अङ्क ३.४ निर्णय नं. ७२०४

²⁵ शंकरप्रसाद विश्वकर्मा विरुद्ध प्रत्यर्थी नेपाल बैंक लिमिटेड, सिद्धार्थनगर शाखा भैरहवासमेत ने.का.प २०६० अङ्क १.२ निर्णय नं. ७१७७

²⁶ दिवाकर शर्मा समेत विरुद्ध छवी नेपाल समेत, निर्णय नं. ७१४६ ने.का.प. २०५९ अङ्क ९/१०

²⁷ सिताराम तामाङ विरुद्ध नेपाल औद्योगिक विकास निगम, काठमाडौंसमेत ने.का.प. २०५९ अङ्क ३/४ निर्णय नं. ७०७५

निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न इन्कार गर्ने हो भने निषेधाज्ञाको आदेशको निष्प्रयोजन हुन जाने स्थिति हुन्छ।²⁸

ज. कसैको निर्विवाद हकमा कसैबाट आघात हुने पर्याप्त आधार र आशंकाको स्थिति विद्यमान छ, निषेधाज्ञा जारी नभएमा निवेदकले अपुरणीय क्षति वेहोर्नु पर्ने स्थिति छ भने मात्र अदालतले हस्तक्षेप गरी निषेधाज्ञा जारी गरी रोक्नु पर्ने हुन आउँछ। निवेदकको लेखाइबाट त्यस्तो स्थिति विद्यमान देखिन नआएकोले निवेदकको माग वमोजिम निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिने।²⁹

ट. बाटो जस्तो कुरामा हस्तक्षेप हुन दिनु कानूनसंगत र न्यायोचित समेत नहुँदा खिचोला मुद्दा समेत अन्तिम किनारा नहुँदा सम्म निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतल पाटनको मिति २०५२।१।२७ को निर्णय आदेश मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्ने।³⁰

ठ. कुनै नागरिकको निर्विवाद सम्पत्तिमा अर्को व्यक्तिद्वारा आघात पार्ने आशंकाको स्थिति विद्यमान भएको अवस्थामा सो रोकौ पहिले जुन अवस्थामा जुन चिज थियो सोही अवस्थामा रहन दिन निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने हो। प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको हक स्वामित्व नै नभएको जग्गामा पसल राखि आएकोमा जनकपुर नगरपालिका कार्यालयबाट पसल हटाउनु भनी पत्र लेखेको कार्यबाट निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गतको सम्पत्ति भोग गर्ने अधिकारमा कानून विपरित आघात पुर्याउने आशंका भएको भन्न सकिने अवस्था नदेखिँने।³¹

ड. ढल नाला आदि निर्माण गर्दा कसैको हक भोगको जग्गा पर्न आएमा कानूनको रीत पुर्याई मात्र जग्गा प्राप्त गर्न सकिन्छ। अन्यथा कसैको हकको जग्गा लिन खोज्नु कानूनसँगत नहुने। निवेदकको हकको घर जग्गा भएको भन्ने कुरामा विवाद नभएको अवस्थामा निजको मन्जुरी वेगर वा कानून वमोजिम बाहेकको नागरिकको वासस्थान पूर्ण वा आंशिक रुपमा क्षति पुर्या उन नमिल्नेमा निवेदकको घरको भाग भत्काउने आशंकाको स्थिति पूर्ण रुपमा देखिँदा निवेदकको घर भत्काउने कार्य नगर्नु भन्ने विपक्षीको नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने।³²

उल्लिखित प्रतिनिधिमूलक व्याख्याका आधारमा हेर्दा सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधारणागत पक्षबाट निर्देशित भएर नै कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गरेको छ। अदालतको व्याख्यामा निवेदनमा उठान गरेका विषयको समन्यायिक दृष्टिकोणले समेत विचार गरी आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय भएको देखिन्छ। मूलरुपमा अदालत निर्विवाद हक अधिकारको संरक्षणका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिने हो भन्ने

²⁸ लक्ष्मीकुमारी मानन्धर विरुद्ध तुयु शाक्य ने.का.प. २०५७ अङ्क १०/११ निर्णय नं. ६९४७

²⁹ अंगद कुमार खनाल विरुद्ध खनाल ट्रेडिङ कम्पनी मुकाम त्रिपुरेश्वर समेत ने.का.प. २०५६ अङ्क १० निर्णय नं. ६७९८

³⁰ कल्पना कुमारी रावला विरुद्ध बुद्धि गोपाल रंजित ने.का.प. २०५६ अङ्क २ निर्णय नं. ६६७२

³¹ राम किसुन मण्डल विरुद्ध जनकपुर नगरपालिका कार्यालय जनकपुर ने.का.प. २०५५ अङ्क १२ निर्णय नं. ६६४४

³² विष्णुकुमारी उपाध्याय विरुद्ध नगेन्द्र राय यादव समेत ने.का.प. २०५४ अङ्क २ निर्णय नं. ६३२२

विषयमा स्पष्ट छ तर कुनै कुनै व्याख्यामा विवादित विषयवस्तुलाई यथास्थितिमा राख्न पनि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता प्रकट भएको देखिन्छ। साथै उल्लिखित व्याख्याले आफूले पालना गर्नु पर्ने कानूनी दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा निवेदकले निषेधाज्ञाबाट उपचार पाउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ भने कानूनी व्यवस्थाको परिपालना भैरहेको विषय निषेधाज्ञाबाट हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा पनि सजग रहेको देखिन्छ। कतिपय व्याख्याहरू तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा आशंकाको अवस्थामा मात्र निषेधाज्ञा जारी हुनेमा कार्य नै सम्पन्न भएपछि निषेधाज्ञाबाट उपचार दिन नसकिने गरी भएका पनि देखिन्छन्। अहिले आशंकाको अवस्थाका साथै कुनै कार्य भएमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिने गरी कानूनी व्यवस्था गरिएको यहाँ विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ।

निषेधाज्ञाको अभ्यास

नेपालको न्यायिक अभ्यास साविकमा अञ्चल अदालतले निषेधाज्ञाको निवेदन सुनुवाइ गर्ने गरेकोमा २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि यो अधिकार साविकको पुनरावेदन अदालतले प्रयोग गर्दथ्यो। पछि न्याय प्रशासन ऐन २०४८ मा भएको २०६७।१२।१५ को संशोधन पछि निषेधाज्ञाको अधिकार जिल्ला अदालतले पनि प्राप्त गरेको थियो। नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएपछि निषेधाज्ञाको निवेदन जिल्ला अदालतले हेर्न सक्ने गरी संवैधानिक प्रबन्ध गरियो। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतमा पनि रहेको छ। उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका आधारमा दुवै अदालतबाट निषेधाज्ञाको निवेदन सुनुवाइ गर्ने गरिएको छ।

हालसम्मको अभ्यास हेर्दा निषेधाज्ञाको निवेदनले हक अधिकारको प्रचलनका लागि सहज पहुँच कायम भएको देखिन्छ। निषेधाज्ञाको निवेदनमा भएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तह पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था समेत रहेको हुँदा जिल्ला अदालतले गरेको आदेश उपर उच्च अदालत र उच्च अदालतले गरेको आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरेको छ।

निषेधाज्ञाको निवेदनको प्रयोग र दुरुपयोग भैरहेको देखिन्छ। हक अधिकारको प्रचलनका लागि पहुँचयोग्य अदालतमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था यसको सकारात्मक पक्ष हो। समयमा नै अन्तरिम आदेश जारी भई अपुरणीय क्षति हुनबाट जोगाउन समेत निषेधाज्ञाको निवेदनले सहयोग पुर्याएको छ। सरकारी वा सार्वजनिक निकाय एवम् संघ संस्था र व्यक्तिका विरुद्ध पनि उपचार खोज्न सकिने भएकोले आफ्नो निर्विवाद हक भोग र स्वामित्व भएको सम्पत्तिको हक र संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको हनन् हुने आशंका रहेको वा हनन् भै रहेको अवस्थामा रोक लगाउन यो आदेश एउटा राम्रो र प्रभावकारी उपचारको माध्यम बन्न सकेको छ। तर यसको प्रयोगका सकारात्मक पक्ष मात्रै रहेका छैनन्। यो रिटको अभ्यासमा अनेकन विकृति पनि रहेको पाइन्छ। खासगरी एउटा अदालतमा निषेधाज्ञाको अभ्यास गरी उपचार पाउन नसकेपछि सो तथ्य लुकाई अर्को अदालतमा निवेदन दिएर अन्तरिम आदेश जारी गराएको अवस्था पनि देखिएको छ। समानान्तर अधिकारक्षेत्रका बारेमा तथ्य लुकाई निवेदन पर्ने संख्या उल्लेख्य रूपमा रहेको छ। कतिपय अवस्थामा निवेदकले

आफूले पालना गर्नु पर्ने दायित्वको पालना नगरी अर्को पक्षबाट हक अधिकार हनन् भएको भन्ने निवेदन पनि उल्लेख्य रुपमा पर्ने गरेको देखिन्छ। एउटै विषयमा एउटै परिवारका सदस्यले आलोपालो निषेधाज्ञाको निवेदन दिएको पनि पाइएको छ। तथ्य ढाँटी एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गराई लामो समयसम्म सो निवेदन किनारा गर्न नदिने गरी सम्बन्धित पक्षले उल्लङ्घन खडा गरेको र अनावश्यक रुपमा कानूनको कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरेको अवस्था पनि देखिन्छ।

खासगरी निषेधाज्ञाको निवेदनमा प्रहरीबाट गैरकानूनी रुपमा धरपकड गर्ने सम्भावना भएको भन्ने, कालो सूचीमा समावेश गर्न लाग्यो भन्ने, विना जानकारी लिलाम गर्न लाग्यो भन्ने, हरहिसावसम्बन्धी मुद्दा परिरहेको अवस्थामा धितो लिलाम गर्न लाग्यो भन्ने जस्ता विषयमा निषेधाज्ञाका निवेदनहरू उल्लेख्य संख्यामा पर्ने गरेका छन्।

निषेधाज्ञाको निवेदन सुनुवाइ प्रक्रिया

निषेधाज्ञाको निवेदन मर्का पर्ने पक्षले आफ्नो हक अधिकार हनन् भएको वा हुने आशंका विद्यमान रहेको आधार र कारण खुलाई उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन्। त्यस्तो निवेदन परेमा सो निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि उच्च अदालतमा एक न्यायाधीशको इजलासमा पेश गरिन्छ। जिल्ला अदालतमा सबै विवादहरू एक न्यायाधीशको इजलासमा नै पेश हुने भएकोले निषेधाज्ञाको निवेदन पनि सोही अनुसार पेश गरिन्छ। पहिलो सुनुवाइमा निवेदकको उपस्थितिमा गरिन्छ र निवेदन उपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिन्छ। प्रारम्भिक सुनुवाइमा निवेदन आवश्यकता अनुसार देहायका आदेश गरिन्छ:

क. निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै उपयुक्त नभएमा खारेज गर्ने वा दावी पुग्न नसक्ने गरी आदेश गरिन्छ।

ख. निवेदन उपर अर्को पक्षको पनि कुरा सुनी निर्णयमा पुग्न उपयुक्त देखिएमा विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिन्छ। कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि निषेधाज्ञाको निवेदन उच्च अदालतको हकमा संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ गरिन्छ। कारण देखाउ आदेश जारी गर्दा बाटाको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनको समय दिने गरिन्छ।

ग. कारण देखाउ आदेशसँगै निवेदकले उठाएको विषयमा प्रथमदृष्टिमा नै विपक्षीले गरे विराए जस्तो देखिएमा वा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखिएमा वा सुविधा र सन्तुलन निवेदकको पक्षमा देखिएमा एकपक्षीय सुनुवाइ कै क्रममा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने (Interim restraining order-IRO) वा अन्तरिम आदेशका लागि अर्को पक्षलाई छलफलमा झिकाउन वा छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश (Interlocutory interim order) जारी गर्न सकिन्छ। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने विषयमा दुवै पक्षसँग छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि अन्तरिम जारी गर्न वा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिएमा सोही बेहोराको आदेश गर्न सकिन्छ।

घ. अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्दछ।³³ एकपक्षीय सुनुवाइको क्रममा जारी भएको अन्तरिम आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउँ भनी निवेदन दिन सक्छ। परिस्थितिमा परिवर्तन भएमा पनि अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा निवेदन दिन सकिन्छ। अन्तरिम आदेश रद्दका लागि परेको निवेदन वा परिस्थितिमा परिवर्तन भई अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दा दुवै पक्षको उपस्थितिमा सुनुवाइ गरिन्छ।

ङ. लिखित जवाफ परे वा अवधि नाँघेपछि पूर्ण सुनुवाइका पेशी चढाई पेश गरिन्छ। निषेधाज्ञाको निवेदनमा आवश्यकता अनुसार अदालतले प्रमाण संकलन गर्न समेत सक्दछ। खास गरी विवादित विषयसँग सम्बन्धित कागजात झिकाउने र विवादित विषयको बस्तुस्थिति खुलाउने गरी आदेश गर्न सकिन्छ।

च. अन्तिम सुनुवाइमा दुवै पक्षका कुरा सुनी पेश भएका आधार र कारणको विवेचना गरी माग बमोजिम permanent injunction को रूपमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न वा निवेदन दावी नपुग्ने गरी आदेश गर्न वा निवेदन खारेज गर्न सकिन्छ। निवेदन खारेज भएमा अन्तरिम आदेश जारी भएको भए त्यस्तो आदेश स्वतः खारेज हुन्छ।

छ. निषेधाज्ञाको निवेदनमा भएको आदेश उपर एक तह माथिको अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्छ।

निषेधाज्ञाको निवेदनका सन्दर्भमा गर्न सकिने सुधारका क्षेत्रहरू

निषेधाज्ञाको निवेदनको कारवाहीमा देखिएका हालसम्मका अभ्यासबाट पहिचान गरिएका समस्याको समाधानका लागि देहायका उपायहरू अबलम्बन गर्न सकिन्छः

- निषेधाज्ञाको निवेदन दिँदा परमादेशसमेतका अन्य रिटको समेत दावी लिने गरेको देखिन्छ। निषेधाज्ञाको निवेदन र रिटको अवधारणागत पक्ष र उपचारको उद्देश्य नै भिन्न भएको र कार्यविधिगत विषय पनि फरक भएको अवस्थामा निषेधाज्ञा र अन्य रिटलाई संयुक्त रूपमा दावी लिई दर्ता गर्ने उच्च अदालतको अभ्यासमा सुधार ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। निषेधाज्ञाको निवेदनमा अन्य रिटको दावी गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
- निषेधाज्ञाको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा रिट निवेदनमा आकर्षित हुने उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ को आधारमा जारी गर्ने गरिएको छ। सो अभ्यासमा पुनरावलोकन गरी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा १५६ बमोजिमका आधारमा जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

³³ अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने र खारेज गर्नुपर्ने अवस्था के कति कारणबाट पर्ने गएको हो सो आदेशमा खुलाउनु पर्ने।
शिवचन्द्र पंडित बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी: जिल्ला विकास समिति पर्सा समेत ने.का.प. २०५९ अङ्क ११/१२ निर्णय नं. ७१४९

- नेपालको संविधानले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई सुम्पिएको अवस्था हुँदा मुलुकी देवानी संहितामा सुधार गरी निषेधाज्ञाको निवेदन जिल्ला अदालतमा मात्र लाग्ने र उच्च अदालतमा सोको पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कार्यबोझ घटाउन पनि सहयोग पुग्दछ भने विवरण ढाँटी समानान्तर अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्न पनि निरुत्साहित तुल्याउँछ।
- निषेधाज्ञाको निवेदनको अवधारणागत पक्ष र यसको अभ्यासका बारेमा सम्बद्ध सबै तहका जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गरिनु पर्दछ।
- निषेधाज्ञाको निवेदनको कारवाही प्रक्रियाका बारेमा न्यायिक दिग्दर्शन तयार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। यस्तो दिग्दर्शनमा प्रतिनिधिमूलक न्यायिक दृष्टिकोणसमेत समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
- निषेधाज्ञाको निवेदनमा खासगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने र नगर्ने अवस्थाका बारेमा सुनुवाइ गर्दा यसको प्रयोजन र सन्दर्भको उचित मूल्यांकन गरिनु पर्दछ। अन्तरिम आदेश जारी गर्दा विचार गर्नु पर्ने पूर्वशर्त वा स्थापित आधार स्पष्ट खुलाउनु पर्दछ।
- गलत विवरण उल्लेख गरी बदनियतपूर्वक निवेदन दिने निवेदकलाई कानूनी व्यवस्था अनुसार दण्डित गरी सोको जानकारी सार्वजनिक गर्न सकेमा यो निवेदनको दुरुपयोग रोक सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
- अन्तरिम आदेश जारी भएको कारण प्रत्यर्थीलाई क्षति पुग्न गएको अवस्थामा त्यस्तो क्षतिको दायित्व निवेदकले व्यहोर्नु पर्ने गरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १६० ले गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सकिने वास्तविक मर्का परेको निवेदकमात्र न्यायिक उपचारका लागि निषेधाज्ञाको माग गरी अदालत आउने अवस्था कायम हुन सक्छ। त्यसतर्फ पनि निषेधाज्ञाको निवेदनको कारवाही प्रक्रियामा विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ।
- निवेदन वा लिखित जवाफमा विवरण ढाँट्ने पक्षहरूलाई सजाय गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेमा मात्र तथ्यपरक रूपमा निवेदन गर्ने वा जवाफ दिने अभ्यास विकास हुन सक्ने देखिन्छ।
- निषेधाज्ञा समन्यायिक उपचारको आधार भएकोले यसलाई कानूनी व्यवस्थाका साथै पक्षलाई वास्तविक उपचार उपलब्ध गराउन सकिने समन्यायिक उपायहरूसमेत आवश्यकता अनुसार अवलम्बन गर्न सकिन्छ। यो विषयमा न्यायिक जनशक्तिलाई अभिमुखीकरणको आवश्यकता रहेको छ।

निष्कर्ष

निषेधाज्ञाको निवेदन निर्विवाद हक अधिकारको हनन् हुनबाट जोगाउनका लागि विकास भएको विशेष उपचारको प्रबन्ध हो। यसको अवधारणा अनुसारको अभ्यास गर्न सकेमा मात्र जिल्ला तहसम्म यो अधिकार प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको सार्थकता कायम हुन सक्छ। निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्दा अर्को पक्षलाई पुग्न सक्ने हानिका बारेमा पनि विचार गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले निषेधाज्ञाको निवेदन सुनुवाइ गर्दा निर्णयकर्ताले एकदम विवेकपरक र होसियारी पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। खासगरी एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरिने विषयलाई अपवादको रूपमा मात्र अभ्यास गरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ। त्यसैगरी

निवेदकले दावी गरेका तथ्य एवम् विवरणको सत्यतालाई पनि पेश भएका कागजातले समर्थन गरेको अवस्था हुनु पर्दछ। समन्यायिक उपचारको अवधारणा भएको कारण निर्णयकर्तले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्दा यसका पूर्वशर्तहरू निर्विवादरूपमा स्थापित भए नभएको तर्फ बस्तुगत मूल्यांकन गरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ।